

REGULACIÓN DE MERCADOS DIGITALES (DMA)

<https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20211209STO19124/la-ley-de-mercados-digitales-y-la-ley-de-servicios-digitales-explicadas>

Claves del nuevo Reglamento de Mercados Digitales aprobado por la Unión Europea (23 de enero de 2023, Ander Romy)

El pasado 12 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 2022/1925, más conocido como Digital Markets Act (“DMA”), la nueva ley reguladora de las plataformas digitales con la que la Comisión Europea pretende regular la actividad de las empresas pertenecientes al entorno digital. Pese a que formalmente entró en vigor el 1 de noviembre de 2022, su contenido no empezará a aplicarse hasta el 2 de mayo del presente año. En este post repasamos las principales claves del nuevo reglamento.

- **¿Qué es la Digital Markets Act (DMA)?**

El Reglamento 2022/1925, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital, o Digital Markets Act, es la nueva normativa para regular la actividad de determinadas plataformas digitales en la Unión Europea. Para ello, el reglamento establece una serie de normas que permitirán a la Comisión Europea ejercer un mayor control sobre las mismas, con el objetivo de impedir que en el futuro puedan darse prácticas restrictivas de la competencia.

- **¿A quién se aplicará la DMA?**

Lo primero que hace el nuevo Reglamento es delimitar el ámbito de aplicación subjetivo de la normativa – esto es, definir a quién le será de aplicación -, y lo hace a través del concepto de “Gatekeeper” o “Guardian de acceso”.

Así, serán designadas como Guardianes de acceso aquellas empresas que:

- ✓ **(i) tengan una gran influencia en el mercado interior,**
- ✓ **(ii) presten un servicio básico de plataforma que sirva como puerta de acceso para que los profesionales lleguen a usuarios finales,**
- ✓ **(iii) tengan una posición afianzada y duradera, o que sea previsible que alcancen dicha posición en el futuro próximo.**

Debido a la poca concreción de los anteriores requisitos, el articulado del Reglamento precisa posteriormente algunas de esas definiciones.

En primer lugar, se define la prestación de un servicio básico de plataforma como aquel a través del cual se ofrecen servicios de intermediación, redes sociales, plataforma de intercambio de videos, comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, computación en

nube o publicidad en línea. También entrarán dentro de esta categoría los motores de búsqueda en línea, los sistemas operativos, los navegadores web y los asistentes virtuales. Como se puede observar, la definición de prestación de servicio básico se enfoca desde una perspectiva amplia, con el objetivo de abarcar el mayor número posible de plataformas en línea.

En segundo lugar, el Reglamento asume que una empresa tendrá una gran influencia en el mercado cuando su volumen de negocios en la Unión Europea haya sido, en los últimos 3 años, igual o superior a 7.500 millones de euros o su capitalización bursátil en el último año haya sido de al menos 75.000 millones de euros, siempre y cuando preste el servicio básico de plataforma en al menos 3 Estados Miembros de la Unión Europea.

En tercer lugar, se entiende que sirven “como puerta de acceso para que los profesionales lleguen a usuarios finales” aquellas plataformas que, en el último año hayan tenido al menos 45 millones mensuales de usuarios activos dentro de la UE, y al menos 10.000 profesionales anuales, tomando como referencia el año anterior.

Por último, se entiende que cumplen el tercer requisito aquellas plataformas que superen el umbral establecido en el apartado anterior durante los últimos 3 ejercicios.

Aquellas empresas propietarias de plataformas que cumplan con los requisitos exigidos por la norma deberán notificar dicha situación a la Comisión Europea. En este sentido, cabe destacar la designación de Gatekeeper no es automática, sino que será la Comisión Europea quien realice el nombramiento una vez recibida la información y escuchada a la empresa afectada.

De igual manera, el Reglamento otorga a la Comisión la facultad de designar a una empresa como Guardián de acceso aunque la misma no cumpla con la obligación de notificar, tras comprobar que supera los umbrales establecidos a través de un estudio de mercado.

De igual forma, la Comisión también podrá designar como Gatekeeper a una empresa que cumpla con los requisitos, aun cuando la misma no supere los umbrales establecidos.

• Principales obligaciones y prohibiciones

Una vez definidos los criterios para la designación de una empresa como Gatekeeper, la DMA expone a continuación una serie de obligaciones y prohibiciones a los mismos. Repasamos a continuación las más importantes:

✓ **Obligaciones de hacer**

1. Permitir que los usuarios profesionales que utilizan los servicios de plataforma puedan promover ofertas y celebrar contratos con los usuarios finales fuera de la propia plataforma propiedad del Guardián de acceso.
2. Permitir a los usuarios finales de la plataforma desinstalar aplicaciones preinstaladas si así lo desean. De igual forma, deberá posibilitar que el usuario pueda modificar con facilidad la configuración por defecto del asistente virtual o del navegador web predeterminado, siempre y cuando estos sean proporcionados por el propio Guardián de acceso.
3. Permitir que puedan instalarse aplicaciones (apps) o tiendas de aplicaciones de terceros.
4. Proporcionar a los usuarios profesionales información gratuita y en tiempo real acerca de los datos, incluyendo los personales, que generen utilizando la plataforma del Gatekeeper

5. Proporcionar a los usuarios a los que la plataforma preste servicios de publicidad información diaria y gratuita acerca de (i) el precio pagado por el anunciante, (ii) la métrica utilizada para el cálculo de dicho precio y (iii) la remuneración recibida por el editor.

También se incluyen ciertas obligaciones para las plataformas que presten servicios de mensajería en materia de interoperabilidad, debiendo garantizar que las plataformas más pequeñas puedan utilizar, a petición de estas, algunas de las funcionalidades de la plataforma del Gatekeeper.

✓ **Obligaciones de no hacer**

1. Abstenerse de aplicar las llamadas “cláusulas de paridad”, a través de las cuales los Gatekeepers obligan a los profesionales a mantener, cuando ofrezcan sus productos a través de su propio canal de venta, los mismos precios y condiciones que en la plataforma del Guardián de acceso.
2. No impedir, ni directa ni indirectamente, que los usuarios profesionales o finales presenten reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones del Guardián ante las autoridades.
3. Abstenerse de obligar a los profesionales a utilizar ciertos servicios accesorios del Gatekeeper (como su sistema de pago).
4. No imponer a los usuarios la obligación de registrarse o suscribirse en otras plataformas, como condición para poder utilizar la plataforma del Guardián de acceso.

• **La DMA y el control de concentraciones**

El reglamento incluye también un artículo relativo al control de concentraciones, donde se determina que, independientemente de su notificabilidad conforme al Reglamento de control de concentraciones o a la legislación nacional, los Guardianes de acceso deberán informar, con carácter preventivo, a la Comisión Europea de cualquier concentración en la que las entidades fusionadas o la empresa resultante de la concentración presten servicios en el sector digital o permitan la recogida de datos.

Pese a que, en principio, la Comisión no dispone de facultades para prohibir o supeditar al cumplimiento de compromisos las concentraciones notificadas conforme a este procedimiento, sí podrá compartir la información recibida con las autoridades nacionales de competencia de los Estados Miembros, a fin de que estos tengan la posibilidad de solicitar a la Comisión que examine la concentración conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de control de concentraciones. Por tanto, se asegura así la posibilidad de que, aunque la concentración no cumpla con los umbrales establecidos, la Comisión pueda terminar examinando la concentración si así lo requiere una o más autoridades nacionales de competencia.

• **Sanciones**

Respecto al régimen sancionador, las multas que se prevén por incumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer establecidas en los apartados anteriores, son de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total de la empresa en el ejercicio anterior, pudiendo incrementarse el límite hasta el 20% en los casos de reincidencia.

También se prevén multas de hasta el 1% del volumen de negocios mundial total del en el ejercicio anterior cuando la empresa:

- (i) no notifique que cumple los umbrales para ser designada como Guardián de acceso,
- (ii) no proporcione la información necesaria para que la Comisión pueda comprobar la designación de la empresa como Guardián de acceso, y
- (iii) cuando la información proporcionada en diferentes contextos (auditoría, inspección, concentraciones, etc.) sea incorrecta, engañosa o incompleta, entre otras.